1ª VARA REGIONAL CÍVEL DE MANGABEIRA - ACERVO B

PROCESSO NÚMERO: 0809293-74.2020.8.15.2003

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO(S): [Fornecimento de medicamentos]

AUTOR: CRISTIANE DE FATIMA COSTA ROQUE, HENRIQUE JORGE BRAGA RESENDE
Advogado do(a) AUTOR: ELINALDA COSTA DE ANDRADE E SILVA - PB11799
Advogado do(a) AUTOR: ELINALDA COSTA DE ANDRADE E SILVA - PB11799

REU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
Advogados do(a) REU: RENILDO SILVA BASTOS BARBOSA - DF65121, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF24923, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF20334, LETICIA FELIX SABOIA - DF58170

SENTENÇA

Vistos.

I – RELATÓRIO

Cuida-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS** ajuizada por **CRISTIANE DE FATIMA COSTA ROQUE** em desfavor da **GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE**, ambos já qualificados nos autos.

Alegou a demandante que: 1) é portadora de câncer anaplasico de tireóide (Neoplasia Maligna de Tireóide) – CID C73.0 - doença rara e agressiva, estando submetida ao tratamento médico com o medicamento LEVANTINIBE, inclusive, a referida medicação está sendo utilizada há 1 (um) ano e meio por parte da autora através de liminar concedida no processo nº 0808359-87.2018.815.2003, que encontra-se em fase de julgamento. 2) houve aparecimento de novas lesões pulmonares, configurando progressão radiológica da doença, além de ter sido observado piora nos sintomas, com a paciente queixando-se de dor na região dorsal. 3) o médico destaca que a única opção para o controle da doença "seria a imunoterapia com PEMBROLIZUMAB 200MG a cada 3 (três) semanas até a progressão da doença, visto que a associando a atual medicação utilizada essa combinação mostrou resultados promissores em estudos de fase 2 apresentado no último Congresso Europeu, ocorrido em setembro/2020 de forma virtual. 4) diante da nova realidade, a promovente buscou o seu plano de saúde, ora promovido, solicitando via administrativo o medicamento para realização do tratamento, mais precisamente no dia 29/10/2020, porém não obteve sucesso, visto que o plano entendeu pela NEGATIVA, tanto do medicamento quanto do tratamento solicitado pelo médico. 5) a consequência é que o contratante do plano de saúde, diante desse tipo de situação, vê-se impossibilitado de usufruir aquilo que foi contratado, aumentando o risco à sua vida e fazendo com que seu tratamento ocorra em condições extremamente gravosas. Além disso, o valor do medicamento versa em média R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Por essas razões, requereu a total procedência do pleito autoral, convolando-se em definitiva a tutela de urgência requerida no sentido de autorização, realização e custeio do tratamento de imunoterapia, à base da medicação Pembrolizumabe 200mg, conforme receita médica, e indenização por danos morais.

Juntou documentos.

Tutela antecipada concedida e justiça gratuita deferida. (Id 36878995)

A ré apresentou petição informando que a tutela vinha sendo cumprida integralmente, entretanto, a autora requereu o cancelamento das solicitações administrativas e autorização para realização do tratamento no Hospital Nossa Senhora das Neves, alegando que se encontrava em recuperação de cirurgia realizada na coluna dorsal, em 03 de março de 2021. (Id 40922895)

Devidamente citada, a ré apresentou contestação alegando, no mérito, em síntese: 1) inexistência de ato ilícito, pois ao receber o pedido a gerência de regulação médica analisou e indeferiu, tendo em vista que "a indicação clínica informada não consta descrita na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), dessa forma não possui obrigatoriedade de cobertura conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 428/2018 da ANS. Solicitamos que verifique com o seu médico uma alternativa para tratamento para que possamos reanalisar o pedido. Logo, o custeio desse medicamento pela GEAP não foi autorizado por não estar em conformidade com as normas, a exemplo da MPP/NTE n° 035/2015, nem com o disposto na Resolução Normativa n° 428/2017 da ANS, razão pela qual houve a aludida recusa; 2) a conduta da GEAP foi regular e lícita, e em nenhum momento foi violado qualquer direito da promovente, haja vista que apenas seguiu seu normativo legal e a Resolução Normativa n° 428/2017 da ANS, não se tratando de negativa arbitrária; 3) rol taxativo da ANS; 4) inexistência de danos morais. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos. (Id 41602499)

Autora requereu cancelamento da audiência, tendo em vista cumprimento da liminar e seu estado de saúde. (Id 42740411).

Audiência de instrução restou prejudicada. (Id 43526767)

Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré. (Id 47224712)

Processo associado ao 0801120-27.2021.8.15.2003 para julgamento em conjunto. (Id 55906816)

Impugnação a contestação apresentada pela autora. Pedido de substituição legal em face ao falecimento da autora. (Id 56491463)

Processo suspenso para habilitação dos herdeiros. (Id 60172676)

HENRIQUE JORGE BRAGA RESENDE requer habilitação como inventariante (id 61975600) e o pedido de sucessão processual da parte autora pelo ESPÓLIO DE CRISTIANE DE FATIMA COSTA ROQUE, representado pelo inventariante HENRIQUE JORGE BRAGA RESENTE, foi deferido. (Id 67000078)

Instadas as partes a informar as provas que pretendiam produzir a parte autora requereu julgamento antecipado da lide (id 67316999) e a ré requereu remessa dos autos ao NATJUS e expedição de ofício à ANS para emitir parecer técnico sobre a obrigatoriedade, no caso concreto, por parte dos planos de saúde, da cobertura do procedimento de tratamento da imunoterapia com PEMBROLIZUMAB 200 MG a cada 3 semanas" (id 67544014)

Sobreveio indeferimento do pedido do réu (id 69405681), o qual deu seu ciente, sem recurso. (Id 69614837)

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o que importa relatar. Passo a fundamentar e decidir conforme o Art. 93, IX da CF/88.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Diante do falecimento da segurada, Sra. **CRISTIANE DE FATIMA COSTA ROQUE**, é o caso de se reconhecer a perda do objeto da presente ação com relação ao pedido de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico), por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível para os sucessores da beneficiária do plano de saúde.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO AUTOR DA AÇÃO. Em sendo a ação exclusivamente cominatória, que versa sobre direito personalíssimo e intransmissível, a morte do autor acarreta a extinção da obrigação, a partir do óbito. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). Beneficiário acometido de câncer com metástase. A linha de tratamento inicial não surtiu o efeito desejado, motivo pelo qual o corpo médico optou pelo tratamento com o quimioterápico Keytruda (pembrolizumabe). A recusa da operadora é abusiva, uma vez que o medicamento tem registro na ANVISA. Desimportante o uso off label ou a ausência no rol da ANS, cujo catálogo de natureza administrativa não pode contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as doenças e seus meios curativos usados com base científica. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO QUE ANTECIPOUOS EFEITOS DA TUTELA. A multa pelo descumprimento da obrigação é devida desde o momento em que o prazo concedido na tutela antecipada se esgotou até o óbito do paciente. Legitimidade do espólio para exigência da satisfação da obrigação. SUCUMBÊNCIA. Ônus sucumbencial mantido. RECURSO PROVIDO NA PARTECONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO." (TJSP; Apelação Cível1043353-74.2017.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento:21/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019)

Assim, a tutela de urgência deferida ao ID 36878995 fica sem efeito a partir de 02/09/2021, data do óbito da segurada (Id 56491477).

Contudo, necessária a análise do mérito com relação aos demais pedidos, a fim de se verificar os direitos dos sucessores (herdeiros) com relação ao pedido de danos morais, já que o direito patrimonial deles decorrentes transmitem-se aos sucessores.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Sentença que julgou procedente a ação, para: (i)condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o procedimento cirúrgico descrito na inicial, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária a contar desta sentença, e de juros de 1% ao mês, a contar da citação – Insurgência da ré – Alegação de que, com o óbito do autor, antes da prolação da sentença, ocorreu a perda do objeto da ação, haja vista que o dano moral tem natureza de direito personalíssimo e intransferível – Não acolhimento - Em que pese tratar-se de direito personalíssimo, a morte do autor, no curso da ação que objetiva indenização por danos morais, não obsta a sucessão processual, uma vez que há transmissão de sua repercussão patrimonial – Inteligência do art. 943, do CC/02 c.c. art. 110, do CPC/15 – Precedentes STJ – Alegação de inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que não demonstrado nos autos o abalo psíquico sofrido pelo autor - Não colhimento - Dano moral caracterizado – Ilícita a negativa de realização de procedimento cirúrgico de urgência do qual necessitava o autor, não há qualquer dúvida que o sentimento de angústia e apreensão por ele vivido, ao ter sua saúde colocada em risco, não se configura como mero aborrecimento da vida cotidiana, mas como dano de ordem moral passível de indenização – Indenização fixada em R$ 10.000,00 - Montante proporcional e razoável para reparar a dor moral sofrida pelo requerente - Alegação de exorbitância no valor fixado a título de honorários advocatícios – Não acolhimento - Valor guarda relação com o encargo assumido pelo causídico da parte adversa – Sentença mantida – Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1012778-79.2017.8.26.0554; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:24/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018)

"PLANO DE SAÚDE – Solicitação de home care com custeio integral dos insumos - Negativa de cobertura - Restrição contratual alegada - Morte do autor da ação no curso do processo - Direito em debate personalíssimo – Extinção de parte do pedido –Pedido indenizatório que subsiste - Dano moral caracterizado – Indenização bem dimensionada - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido. (TJSP; ApelaçãoCível 1021413-16.2014.8.26.0405; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ªCâmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento:30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

No mérito, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, por tratar de matéria de fato e de direito que não demanda dilação probatória.

Importa ressaltar de início que o fato do entendimento do STJ ser pela inaplicabilidade do CDC ao pacto em apreço, esse não afasta a incidência das regras atinentes aos contratos de adesão, disciplinados, de forma geral, pelo Código Civil.

Impõe-se registrar também que os fatos articulados na inicial são incontroversos, porque alegados pela demandante e admitidos pela demandada.

Colhe-se dos autos que a autora era portadora de câncer (Neoplasia Maligna de Tireóide) – CID C73.0. Após a realização de exames, oanaplasico de tireóide, o médico que o acompanhava prescreveu tratamento de imunoterapia com PEMBROLIZUMAB 200MG a cada 3 (três) semanas, associado com a medicação que já tomava (LEVANTINIBE), devido ao aparecimento de novas lesões pulmonares, configurando progressão radiológica da doença, cuja cobertura foi negada pela ré.

Cinge-se a controvérsia apenas em relação regularidade ou não da negativa do fornecimento do supracitado medicamento para o tratamento do quadro da autora, em razão da não previsibilidade no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e demais normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

Da análise entre a pretensão e a resistência, bem como diante dos documentos colacionados aos autos, tenho que a ação é procedente.

A autora comprovou que era usuária do plano de saúde administrado pela empresa ré (Id 55590761) bem como portadora de câncer (Neoplasia Maligna de Tireóide) – CID C73., por meio dos exames e os relatórios médicos acostados à inicial, o qual estava fazendo tratamento.

O laudo médico acostado à inicial fornecido pela Dra. Cristiane de Fátima Roque Braga, constante no ID 36662024 assim consta: *"(...) Eu entendo que a nossa única opção para controle de doença seja imunoterapia, pembrolizumab 200mg a cada 3 semanas, até progressão da doença, associando a atual medicação utilizada. Essa combinação mostrou resultados promissores em estudo fase 2 apresentado no último congresso (...)".*

Percebe-se, portanto, que protocolo anterior não impediu a progressão da doença, inclusive justificando o profissional médico que o atualmente solicitado, objeto desta demanda, já foi testado extensamente na literatura, com resultados favoráveis.

O tratamento, prescrito pela médica e negado pelo demandado, é composto de medicamentos que, inclusive, são registrados pela ANVISA, embora a utilização seja apontada pela parte demanda como de uso off label.

Cumpre ressaltar que a determinação do tipo de tratamento que será realizado pelo usuário cabe ao médico que o assiste, desde que possível sua realização, não ao plano de saúde. Ademais, impõe-se registrar que o plano, ao negar a cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente, não indicou qual seria a alternativa de tratamento a ser administrado à parte promovente, com supedâneo no rol da ANS, igualmente adequado a combater a doença que lhe aflige, a afastar sua obrigação de cobertura.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 08/06/2022, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), portanto, as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Todavia, o STJ fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Senão vejamos as teses definidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

1) O rol de procedimentos em eventos da saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2) A operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3) É possível a contratação de cobertura ampliada ou aditivo contratual para cobertura de procedimento não incluindo no rol;

4) Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente desde que:

1) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde complementar;

2) Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da Medicina baseada em evidências;

3) Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros, tais como Conitec e NatJus;

4) Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional dos magistrados com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos em saúde suplementar, sem o deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva da causam da ANS. STJ. 2ª Seção. EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022.

Ademais, ressalta-se que em setembro do ano de 2022 foi publicada a Lei nº 14.454, a qual adicionou ao art. 10 da Lei nº 9.656/98 os §§ 12 e 13, que assim dispõem:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um)órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Impede dizer que não se trata de garantir cobertura irrestrita ao usuário do plano, ou aferir direitos além dos avençados, mas promover o tratamento necessário, proporcionando-lhe o reestabelecimento da saúde e qualidade de vida, mormente em observância ao direito constitucionalmente garantido de uma vida digna.

É incontroversa a cobertura do plano de saúde para a enfermidade que acometia a requerente, portanto, não se mostrava cabível a conduta da ré que buscou limitar o tipo de tratamento a que devia se submeter a paciente.

À evidência, a obrigação de arcar com o serviço e a metodologia a ser aplicada não é de escolha do plano de saúde, mas sim do médico que acompanha o paciente. Desse modo, não poderia a empresa ré se negar, sob a justificativa da não inclusão do tratamento no rol da ANS, a custear o tratamento indicado pelo médico da paciente, que prediz expressamente a necessidade de tratamento de **imunoterapia com PEMBROLIZUMAB 200MG a cada 3 (três) semanas, associado com a medicação que já tomava (LEVANTINIBE),** uma vez já ter feito uso de vários outros tratamentos, e a doença continuar evoluindo.

Assim, se mostra ilegal recusa de tratamento com base em exclusão no rol da ANS, caso não demonstrado qualquer fato que afaste a comprovação da eficácia do tratamento indicado a autora, o qual foi respaldado pelo médico que a acompanha.

Portanto, verifica-se que a parte autora logrou êxito na comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; em contrapartida, o réu não se desincumbiu do art. 373, II, do CPC, não tendo demonstrado nos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor no que concerne ao pedido de obrigação de fazer.

Procede o pedido para condenação da ré a custear o procedimento indicado pelo profissional especializado.

Nesse mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRIBUNAL *DE* JUSTIÇA DO ESTADO *DE* SÃO PAULO COMARCA *DE de* SÃO PAULO. SENTENÇA CONCLUSÃO Em 24 *de* novembro *de* 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz *de* Direito, Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia. Eu, MSO, escrevente, subscrevi. Processo: 1012743-26.2022.8.26.0011 - *Procedimento* Comum Cível Requerente: Cláudio Ruiz Daró Requerido: Amil Assistência Médica Internacional S/A Juiz(a) *de* Direito: Dr(a). PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA Vistos. CLÁUDIO RUIZ DARÓ ajuizou o presente PEDIDO CONDENATÓRIO em face *de* AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., afirmando ser beneficiária *de* plano *de* seguro saúde fornecido pela Ré e que, em razão do seu quadro *de* esquizofrenia paranoide, foi submetido a internação para tratamento no Hospital Albert Einstein, por 22 dias, em regime *de* urgência, e passou por 30 sessões *de eletroconvulsoterapia*, 24 atendimentos médicos, 16 consultas médicas e 2 anestesias. Alega que a requerida se recusou ao reembolso integral das despesas médicas. Requer seja a ré condenada ao custeio integral do *procedimento* prescrito e ao pagamento *de* danos morais no valor *de* R$ 10.000.00. Juntou documentos. Citada, a Ré apresentou contestação em que sustentou a impossibilidade *de* reembolso integral em razão das cláusulas contratuais livremente acordadas. Sustentou a ausência *de* previsão do tratamento no rol da ANS e que a recusa é legítima. Houve Réplica. É o relatório. Fundamento e decido. Julgo o feito no estado considerando que as partes não requereram a produção *de* outras provas. No mérito, o pedido é procedente. Trata-se *de* demanda em que se discute o reembolso das despesas no tratamento médico da parte autora, por força *de* contrato *de* plano *de* seguro-saúde havido entre as partes, bem como *de* despesas em que existe recusa da ré, sob alegação *de* ausência *de* cobertura contratual. Com relação aos procedimentos indicados, é o caso *de* se reconhecer a abusividade da recusa. Antes *de* se sujeitar às normas e procedimentos do Ministério da Saúde, o contrato deve observar o Código *de* Defesa do Consumidor. No caso, não se desconhece ser possível ao fornecedor o estabelecimento *de* restrições ao custeio do objeto do contrato, devendo ser respeitados, entretanto, os parâmetros legais. Neste sentido, uma vez presente doença objeto *de* cobertura, resta configurada cláusula potestativa, sendo ilegal, portanto, deixar ao critério do segurador a fixação *de* qual tratamento deve ser utilizado, o que configuraria notória atividade *de* alteração unilateral do risco do contrato, ou seja, uma vantagem abusiva do fornecedor em detrimento do consumidor. Com efeito, havendo no contrato cobertura para a doença indicada, não cabe à Ré escolher qual *procedimento* deve ser utilizado para o tratamento, pois haveria indevida ingerência na questão técnica médica, *de* modo a afetar a própria álea do contrato. Ademais, o contrato *de* plano *de* saúde ostenta uma função social que é a *de* preservação da vida das pessoas por meio *de* tratamento médico, assim a negativa *de* utilização do método mais eficiente, seguindo a prescrição médica indicada por profissional habilitado, configuraria violação da própria finalidade do contrato. Assim, em se aplicando a cláusula *de* exclusão da cobertura, haveria violação da própria finalidade do contrato, o que deixa evidente a abusividade indicada. *De* se observar que o artigo 10 da Lei 9.656/98 não configura cláusula *de* exclusão, mas sim a cobertura mínima que as operadoras *de* planos privados *de* assistência à saúde deverão observar, o que não afasta a possibilidade *de* cobertura maior. Logo, considerando que o *procedimento* possui registro ativo na ANVISA, deve a ré custear o tratamento indicado, sob pena *de* infringir o disposto no artigo 51 inciso IV do Código *de* Defesa do Consumidor, na medida em que coloca a paciente em desvantagem exagerada, mas sem obrigação *de* proceder à importação, por configurar questão alheia ao contrato *de* custeio do serviço *de* saúde e não fornecimento dele. Impede dizer que não se trata *de* garantir cobertura irrestrita ao usuário do plano, ou aferir direitos além dos avençados, mas promover o tratamento necessário, proporcionando-lhe o reestabelecimento da saúde e qualidade *de* vida, mormente em observância ao direito constitucionalmente garantido *de* uma vida digna. Ademais, ressalta-se que em setembro do ano corrente foi publicada a Lei nº 14.454, a qual adicionou ao art. 10 da Lei nº 9.656/98 os §§ 12 e 13, que assim dispõem: § 12. O rol *de* procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados *de* assistência à saúde contratados a partir *de* 1º *de* janeiro *de* 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes *de* atenção à saúde. § 13. Em caso *de* tratamento ou *procedimento* prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora *de* planos *de* assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional *de* Incorporação *de* Tecnologias no Sistema Único *de* Saúde (Conitec), ou exista recomendação *de*, no mínimo, 1 (um) órgão *de* avaliação *de* tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." Destarte, se mostra ilegal recusa *de* tratamento com base em exclusão no rol da ANS, caso não demonstrado qualquer fato que afaste a comprovação da eficácia do tratamento indicado ao autor, o qual foi respaldado pelos médicos que o acompanham em hospital reconhecido no país, sendo *de* rigor o reembolso das despesas do tratamento realizado pelo autor nos dias em que esteve internado, nos percentuais previstos contratualmente. Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, este

não procede. Isto porque, a mera negativa *de* cobertura baseada em interpretação *de* cláusula contratual não representa, por si só,ato ilícito. Também da simples negativa não se presume dano moral passível *de* indenização. Com efeito, a parte necessita narrar e demonstrar transtornos graves que justifiquem o pagamento da verba, o que não se verifica descrito na inicial. Anoto que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, *de* infirmar a conclusão adotada neste julgamento (CPC, art. 489, § 1º, inciso IV). Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código *de* Processo Civil, DECIDO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por CLÁUDIO RUIZ DARÓ em face *de* AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para condenar a ré ao reembolso das despesas decorrente da internação hospitalar e honorários médicos referentes ao tratamento indicado na inícial, respeitando-se os limites contratuais. Sucumbente em maior parte, arcará a Ré com as custas, despesas processuais, mais honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo em 10% do proveito econômico obtido (valor do reembolso). P.R.I.C. São Paulo, 24 *de* novembro *de* 2022. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA Juiz *de* Direito.

Assim, patente que a segurada fazia jus ao tratamento até a data de seu óbito. Como dito alhures, embora seu falecimento implique a perda do objeto quanto ao pedido de custeio da terapia, referida análise é necessária para preservar os demais direitos provenientes da ilegalidade da negativa.

Nesse diapasão, verifica-se que o pedido de indenização por danos morais comporta acolhimento, pois a negativa da ré foi ilegal e gerou dano moral indenizável.

A negativa *injustificada* do réu ao fornecimento *de* tratamento ao qual a requerente tinha direito, *para* prevenção *de* eventual agravamento *de* sua doença, com vistas a evitar maior sofrimento, cuja *demora* ou negativa poderia ensejar graves consequências à saúde ou até mesmo à vida, certamente lesou direitos da personalidade como a dignidade, o próprio direito à saúde, a tranquilidade e outros.

É certo que, em se tratando de relação contratual, o mero inadimplemento, em princípio, não é gerador de prejuízo de ordem moral. Porém, não se pode ignorar que, no caso em discussão, numa situação em que a segurada enfrentava doença grave e com sérias e notórias repercussões em seu bem estar (Neoplasia Maligna de Tireóide), o descumprimento de contrato firmado como fito de garantir atendimento médico, é, sim, causador de abalo, angústia e aflição psicológica que configuram dano moral indenizável, conforme vem decidindo o **C. Superior Tribunal de Justiça** (Recurso Especial nº 907.718 - ES (2006/0266103-0), Rel.Ministra Nancy Andrighi):

"(...) de início, o Tribunal não reconhecia o direito à compensação, vislumbrando mero inadimplemento contratual nessas circunstâncias; porém, a partir de 2004, 'passou-se a adotar tese segundo a qual o dano moral pela indevida recusa em fornecer o serviço de seguro esperado pelo consumidor, **em momento de extrema angústia como a que se analisa nos presentes autos, decorre diretamente desse próprio fato** (...).Embora se reconheça que a regra geral, nessa matéria, seja a de que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, verifica-se que, nas hipóteses como a que por ora se examina, a jurisprudência do STJ tem aberto uma exceção, pois na própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material é possível verificar consequências bastante sérias de cunho psicológico que são resultado direto do inadimplemento culposo. O i. Min. Jorge Scartezzini proferiu voto bastante claro nesse sentido ao julgar o REsp nº 880.035/PR, consignando na própria ementa que 'já tem decidido esta Corte, em casos como este não é preciso que se demonstre a existência do dano extrapatrimonial. Acha-se ele in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação' (4ª Turma, j. em 21.22.2006, DJ de 18.12.2006)".

Ademais, não se pode deixar de olvidar que a parte autora precisou entrar com um primeiro processo judicial para ter garantido o direito a medicação para controle da doença, qual seja, o LEVANTINIBE (Processo nº 0808359-87.2018.815.2003). Posteriormente, devido ao aparecimento de novas lesões a de cujus necessitou de complementação da medicação, necessitando fazer uso do PEMBROLIZUMAB, o que novamente foi negado pelo plano, obrigando a autora a novamente adentrar com processo e lutar pela sua saúde, aumentando imensamente o momento de angústia já vivido com a doença e seu avanço. E, por outro lado, caracterizando a reiterada conduta abusiva da ré.

Inclusive, na própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito é possível verificar consequências bastante sérias de cunho psicológico que são resultado direto do inadimplemento culposo da ré.

Induvidosa, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável, entendimento deveras exarado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em casos similares ao dos autos. Vejamos:

TRIBUNAL *DE* JUSTIÇA DO ESTADO *DE* SÃO PAULO COMARCA *de* Santo André Foro *de* Santo André 9ª Vara Cível Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09040-906 Horário *de* Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 1017756-26.2022.8.26.0554 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 1017756-26.2022.8.26.0554 Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar Requerente: Maria Inês Petini Velensuela Requerido: Sul América Companhia *de* Seguro Saúde Prioridade Idoso Tramitação prioritária Justiça Gratuita Juiz(a) *de* Direito: Dr(a). SIDNEI VIEIRA DA SILVA Vistos. MARIA INÊS PETINI VELENSUELA, qualificada nos autos, propôs ação *de* obrigação *de* fazer cumulada com indenização por danos morais em face *de* BRADESCO SAÚDE S/A, também qualificado, alegando, em síntese, que é beneficiária do plano *de* saúde ofertado pela requerida e que foi diagnosticado com estenose valvar aórtica grave. Informou que há recomendação médica *para* tratamento denominado "implante percutâneo *de* prótese valvar aórtica (TAVI)". Ressaltou que houve negativa do plano *de* saúde sob o argumento *de* que não há previsão contratual *para* o custeio do tratamento. Ao final, postulou pela concessão *de* tutela provisória e pugnou pela procedência dos pedidos *para* a) condenar a requerida a arcar com o tratamento integral indicado pelo médico; b) condenar a requerida ao pagamento *de* indenização por danos morais no importe *de* R$ 15.000,00. Juntou documentos (págs. 16/50). Deferida a tutela provisória e concedido o benefício da Justiça Gratuita (págs. 51/52). Citada, a requerida apresentou contestação às págs. 78/91. Aduziu que o contrato da autora é anterior a Lei dos Planos *de* Saúde e não é adaptado. Afirma que não há urgência ou emergência na *cirurgia*, razão pela qual lícita a exclusão contratual *de* cirurgias eletivas. Sustentou que não há abusividade ou danos morais indenizáveis. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos (págs. 92/108). Houve réplica (págs. 117/126). Instadas a especificar as provas que pretendem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado (págs. 112/116 e 125/126) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código *de* Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado da lide, haja vista a desnecessidade *de* produção *de* provas, bastando, *para* a solução do conflito *de* interesses, os documentos já carreados aos autos, não havendo matéria fática dependente *de* dilação probatória, sobretudo ante a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, com o que se operou a preclusão probatória. Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal *de* Justiça do Estado *de* São Paulo: "JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Cerceamento *de* defesa - Inocorrência - Silêncio das partes quanto a despacho que determinou a especificação *de* provas - Preclusão consumada - Recurso improvido." (Apelação Cível n. 920.061-7 - Fartura - 20ª Câmara *de* Direito Privado - Relator: Luis Carlos *de* Barros - 18.10.05 - V. U. - Voto n. 11.138). A ação é procedente. Impende, *de* início, consignar que se trata *de* relação consumerista, razão pela qual deverá ser aplicado aqui o disposto no Código *de* Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/1990), posto que a autora preenche as características *de* consumidor, bem como a requerida, as características *de* fornecedora, conforme os artigos 2° e 3°, respectivamente, do referido Diploma Legal. Não obstante, os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes *de* legislação ordinária, desde que mais benéficos ao consumidor (art. 7°, da Lei). Ante a relação existente entre as partes, forçoso se reconhecer a necessidade *de* inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código *de* Defesa do Consumidor e, a ré, como se verifica, não se desincumbiu *de* seu ônus. Em que pese se tratar *de* contrato não adaptado à Lei dos Planos *de* Saúde, é preciso destacar que a relação havida entre as partes é *de* consumo, nos termos da Súmula 100 do Tribunal *de* Justiça *de* São Paulo e Súmula 608 do C. STJ: "Súmula 100: O contrato *de* plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código *de* Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais." "Súmula 608: Aplica-se o Código *de* Defesa do Consumidor aos contratos *de* plano *de* saúde, salvo os administrados por entidades *de* autogestão." Conforme se depreende do laudo médico *de* págs. 24/25, a autora tem diagnóstico *de* estenose valvar aórtica grave e foi solicitado, com urgência, *autorização para* o procedimento *de* implante percuntâneo *de* proteste valvar (TAVI). Nesse contexto, observa-se que não se trata *de* procedimento eletivo, mas sim *cirurgia de* urgência e emergência. Ainda que assim não fosse, a despeito da exclusão contratual *de* procedimentos eletivos, trata-se *de* tratamento necessário à saúde da autora, afigurando-se abusiva a negativa *de* cobertura da *cirurgia* em questão, por implicar uma desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, do CDC). Destaco o entendimento do Tribunal *de* Justiça em sede do agravo *de* instrumento interposto pela requerida: "(...) consubstanciada no fato *de* que é abusiva a cláusula contratual *de* plano *de* saúde e *de* seguro saúde que exclua a cobertura *de* prótese necessária ao restabelecimento da saúde, pois restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do art. 51, § 1º, inc. II, do Código *de* Defesa do Consumidor". Além disso, as seguradoras podem delimitar as doenças objeto do plano *de* saúde, mas não as opções *de* tratamento. Deste modo, a requerida tem o dever *de* arcar com todos os tratamentos indicados pelo médico

que assiste a autora, a fim *de* alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade. Este é o entendimento do C. Tribunal *de* Justiça do Estado *de* São Paulo, refletido nas súmulas 95, 96 e 102: Súmula 95:"Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa *de* cobertura *de* custeio ou fornecimento *de* medicamentos associados a tratamento quimioterápico". Sumula 96: " Havendo expressa indicação médica *de* exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa *de* cobertura do procedimento". Súmula 102: "Dispõe que havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa *de* cobertura *de* custeio *de* tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol *de* procedimentos da ANS". Do mesmo modo, ressalto o decido em sede *de* agravo: "Enfim, se a ré obrigou-se a custear o procedimento cirúrgico *para* reparar insuficiência cardíaca, e não há como ser feita tal intervenção sem o IMPLANTE PERCUTÂNEO *DE* PRÓTESE VALVAR AÓRTICA, por óbvio deve arcar com a implantação desta prótese também, aqui se afigurando intrínseca ao ato cirúrgico, sem o que a *cirurgia* não alcançaria o sucesso almejado e não atingiria sua finalidade; daí a necessidade *de* atendimento completo às recomendações dos especialistas que a assistem. Achando-se prevista a cobertura do mal *de* que padece a agravada, todos os meios necessários ao tratamento devem ser fornecidos, *de* acordo inclusive com a legislação consumerista. Cláusulas dessa ordem, entretanto, são tidas por abusivas e leoninas, que ferem normas previstas tanto no texto constitucional como no Código *de* Defesa do Consumidor" (RT 787/335). Ora, existindo prescrição médica *para* a realização *de* tal procedimento cirúrgico, é imperiosa a cobertura pelo plano *de* saúde, como vem decidindo este Egrégio Tribunal *de* Justiça". Assim, resta patente a obrigação da requerida *de* autorizar e custear todo o tratamento na forma indicada pelo médico (pág. 24), com o custeio do procedimento *de* implante percutâneo *de* prótese valvar aórtica por cateter e outros materiais e procedimentos que se fizerem necessários durante o tratamento cardíaco da autora. Em relação aos danos morais, igualmente, comporta acolhimento o pedido do autor. A negativa *injustificada* do réu ao fornecimento *de* tratamento ao qual o requerente tem direito, *para* prevenção *de* eventual agravamento *de* sua doença, com vistas a evitar maior sofrimento, cuja *demora* ou negativa pode ensejar graves consequências à saúde ou até mesmo à vida, certamente lesou direitos da personalidade como a dignidade, o próprio direito à saúde, a tranquilidade e outros. É certo que tal indenização compreende uma satisfação compensatória aos direitos violados, não havendo propriamente como serem provados tais danos, uma vez que não têm repercussão direta no patrimônio do ofendido, bastando, pois, a prova da ofensa, como acima demonstrado. Há que se ressaltar, ainda, que a indenização do dano moral não deve ser arbitrada *de* forma a se tornar fonte *de* enriquecimento da parte que a pleiteia, deve guardar proporcionalidade com a situação concreta. Nesse sentido: "Dano moral- Indenização- Inexistência *de* repercussões justificadoras *de* quantia elevada- Arbitramento moderado e equitativo mantido- Recurso adesivo improvido. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderada e equitativamente *para* que se não converta o sofrimento em móvel *de* captação *de* lucro". (2º TACiv- Ap. C/Rev. 507.724- 2ª Câm. Rel. Juiz Gilberto dos Santos- J. 09/03/1998)- AASP no. 2063 *de* 13 a 19/07/98, p. 5.). Destarte, considerando o fato em si, o grau *de* culpa da ré, conforme já especificado, as consequências do fato, impende fixar valor que, forma razoável e justa, contemple o dano moral experimentado pelo autor, arbitrando-se, pois, este Juízo a quantia *de* R$ 8.000,00 (oito mil reais). Tal importância será acrescida *de* correção monetária pela tabela do Tribunal *de* Justiça do Estado *de* São Paulo a partir da publicação e juros *de* mora *de* 1% ao mês a partir da citação, dada a relação contratual existente entre as partes. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, extinguindo o processo, com resolução *de* mérito, nos termos do art. 487, I, do Código *de* Processo Civil *para*: i) DETERMINAR que a requerida autorize e custeie todo o tratamento na forma indicada pelo médico (pág. 24), cobrindo as despesas do procedimento *de* implante percutâneo *de* prótese valvar aórtica por cateter e outros materiais e procedimentos que se fizerem necessários durante o tratamento cardíaco da autora, confirmando-se a tutela provisória *de* págs. 51/52; ii) condenar a requerida ao pagamento *de* indenização por danos morais no valor *de* R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência *de* correção monetária pela tabela do Tribunal *de* Justiça do Estado *de* São Paulo a partir da publicação e juros *de* mora *de* 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência e observada a Súmula nº. 326 do STJ, arcará a requerida com as custas e despesas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, considerando, em especial, o trabalho realizado, o tempo decorrido, a matéria em questão, a duplicidade *de* pedidos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código *de* Processo Civil. Incide correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal *de* Justiça *de* São Paulo, com juros moratórios *de* 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16 do CPC. Em caso *de* recurso *de* apelação, ciência à parte contrária *para*, querendo, apresentar contrarrazões no prazo *de* 15 dias úteis (art. 1.010, §1º do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal *de* Justiça *de* São Paulo, com nossas homenagens e cautelas *de* estilo. Com o advento da Lei nº 13.105/2015, o juízo *de* admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3º, a

seguir transcrito: Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente *de* juízo *de* admissibilidade. Com o trânsito em julgado, não procedendo a requerida ao recolhimento das custas, intime-a via postal *para* fazê-lo em quinze dias. Após, na inércia, expeça-se certidão *para* inscrição em dívida ativa. No mais, sem manifestação das partes em termos *de* prosseguimento em 30 dias, feitas as devidas anotações, arquivem-se os autos. P.I.C. Santo André, 22 *de* novembro *de* 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

É certo que tal indenização compreende uma satisfação compensatória aos direitos violados, não havendo propriamente como serem provados tais danos, uma vez que não têm repercussão direta no patrimônio da ofendida, bastando, pois, a prova da ofensa, como acima demonstrado.

Há que se ressaltar, ainda, que a indenização do dano moral não deve ser arbitrada *de* forma a se tornar fonte *de* enriquecimento da parte que a pleiteia, deve guardar proporcionalidade com a situação concreta.

Com relação ao quantum da indenização, deve-se levar em conta, no momento do arbitramento, seu caráter compensatório, bem como seu aspecto de prevenção quanto à reiteração de condutas dessa espécie, sem implicar, por outro lado, em enriquecimento indevido por parte das autoras.

Considerando tais aspectos, assim como a doença que acometia a segurada, de indiscutíveis gravidade e risco à vida, a indenização é fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência provisória, tornando-a definitiva, até a data do óbito da segura, em 02/09/2021 e condenar a demandada a pagar a parte autora, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (24/11/2020).

Condeno a ré vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º e incisos do CPC.

Interpostos embargos ou recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões.

Transitada em julgado a sentença: 1) intime-se a parte autora pra, querendo, em 15 (quinze) dias, requerer a execução do julgado; 2) nos termos do Provimento CGJ/PB nº 28/2017, calculem-se as custas, intimando-se a parte sucumbente, através de advogado (intimação eletrônica), para recolhê-las, de forma integral ou na proporção que lhe couber, a depender do que foi estabelecido em sentença/acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, implicando sua inércia em protesto e inscrição na dívida ativa.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa/PB, data do protocolo eletrônico.

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006]
GABRIELLA DE BRITTO LYRA LEITÃO NÓBREGA - Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: GABRIELLA DE BRITTO LYRA LEITAO NOBREGA
11/04/2023 09:20:47
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 71165902

23041109204573100000006

IMPRIMIR GERAR PDF